

第2編 ■ 犯罪

第1章 犯罪の概念

刑法
No8

H18-6

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【記述】中の①から⑧までの（ ）内に後記の【語句群】から適切な語句を入れた場合、（ ）内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

「犯罪の終了時期に関し、各犯罪は即成犯、①及び②に区別される。殺人罪は即成犯であり、③は①であり、④は②である。ある犯罪が①か②かの区別は、⑤の起算時期や⑥の成立範囲に影響があるとされる。この区別の基準について、実行行為を基準にする考え方と法益侵害を基準にする考え方がある。被害者を部屋に閉じ込めた後、行為者が眠ってしまった監禁の事例について、前者の考え方は、被害者を閉じ込めたまま解放しないことを実行行為と評価して継続犯であるとするのに対し、後者の考え方は、⑦を理由に継続犯であるとする。さらに、前者の考え方は、傷害罪について、一回の暴行によって傷害を発生させたような一般的な態様の場合は、①とするが、⑧のような特別な態様の場合は、②であるとする。」

【語句群】

- a. 継続犯 b. 状態犯 c. 窃盗罪 d. 監禁罪
e. 刑の時効 f. 公訴時効 g. 間接正犯 h. 共犯
i. 不作為による実行行為が継続していること
j. 被害者の移動の自由が刻々と侵害されていること
k. 身体を動かすたびに傷害を負うように被害者の身体をきつく縄で縛り継続的に傷害を与えた事例
l. 刃物で被害者の手の指を切断し被害者の物をつかむ機能を永続的に侵害した事例
1. ①b③c⑤e 2. ①a④d⑥g 3. ②a④c⑦i
4. ③c⑦j⑧k 5. ⑤f⑥h⑧l

№8	犯罪の終了時期	正答率
H18-6	正解 4	82%

() には、順に、① = b、② = a、③ = c、④ = d、⑤ = f、⑥ = h、⑦ = j、⑧ = k と入り、したがって、正解は肢 4 となる。

【語句の穴埋めについて】

① b ② a

「犯罪の終了時期に関し、各犯罪は即成犯、(①) 及び (②) に区別される」という文言から、①及び②には犯罪の終了によって区別される犯罪の概念が入ることが分かる。この点、法益侵害が、瞬時に終了するのか、法益侵害状態が継続するのか、法益侵害の継続と犯罪の終了がどのような関係に立つかに応じて、即成犯、継続犯、状態犯に区別される。記述には既に即成犯があるため、①及び②には「a. 継続犯」か「b. 状態犯」のいずれかが入るが、この時点では①及び②のいずれの空欄に入るかは明らかではない。そして、「前者の考え方は、傷害罪について、一回の暴行によって傷害を発生させたような一般的な態様の場合は (①) とする」とあるが、前者の考え方つまり、実行行為を基準とする考え方によると、例えば、刀で傷つけたが、その傷跡が残っているような一般的な態様の場合、傷つけた時に犯罪は成立すると同時に終了し、後は違法な状態が残っているにすぎないと解されるため、傷害罪を原則、状態犯と理解することになる。したがって、①には b が入ることが分かり、そして②に a が入ることが分かる。

③ c ④ d

「殺人罪は即成犯であり、(③) は (①b. 状態犯) であり、(④) は (②a. 継続犯) である。」という文言から、③及び④には、①及び②の例となる具体的な犯罪の名称が入ることが分かる。そこで語句群をみるに、「c. 窃盗罪」「d. 監禁罪」がある。状態犯とは、一定の法益侵害の発生によって犯罪は終了し、その後、法益の侵害されている状態は存続しても、それは、犯罪事実とはみられないものをいう。窃盗罪がその例とされている。他方、継続犯とは、一定の法益侵害が継続する間、犯罪の継続が認められるものをいう。例えば、監禁罪がこれにあたる。したがって、状態犯の具体例たる「c. 窃盗罪」が③に、継続犯の具体例たる「d. 監禁罪」が④に入ることが分かる。

⑤ f

「(⑤) の起算時期」という文言から、⑤には「e. 刑の時効」か「f. 公訴時効」のいずれかが入ることが分かる。この点、判例（最決昭 63.2.29）は、刑法 253 条 1 項において時効の起算点とされている「犯罪行為」には、刑法各条所定の結果を含むとしており、犯罪が終了しない間は、公訴時効は進行しないから、終了時点を選定することは實際上重要な意義を有するとされる。したがって、⑤には f が入ることが分かる。

⑥ h

「(⑥) の成立範囲」という文言から、⑥には「g. 間接正犯」か「h. 共犯」のいずれかが入ることが分かる。この点、状態犯の場合、犯罪が終了した後も違法状態が残るものの、それは構成要件に該当する結果ではないために、その違法状態の維持・促進に関与しても、既に終了した犯罪の共犯とはならないのに対して、継続犯の場合には共犯になるとされる。したがって、⑥には h が入ることが分かる。

⑦ j

「後者の考え方は、(⑦)を理由に継続犯であるとする」との文言から、⑦には「被害者を部屋に閉じ込めた後、行為者が眠ってしまった監禁の事例」において、継続犯と状態犯の区別につき「法益侵害を基準にする考え方」を根拠とした場合、継続犯となる理由が入ることが分かる。この点、継続犯と状態犯の区別を、法益侵害を基準にする見解によれば、継続犯は、法益侵害などの結果が持続する間成立し続けるが、それは構成要件要素である法益侵害などの結果の惹起が持続的に肯定され、構成要件該当性が持続的に肯定されるからと説明される。そうすると、監禁罪は、場所的移動の自由が侵害されることにより成立し、それが侵害され続けている間継続的に成立し続けるが、それは構成要件要素である場所的移動の自由の侵害が、持続的に肯定され、当初の行為との間において持続的な構成要件該当性を肯定し得ることを理由としている。したがって、⑦には、「j. 被害者の移動の自由が刻々と侵害されていること」が入ることが分かる。

⑧ k

「前者の考え方は、傷害罪について、……(⑧)のような特別な態様の場合には、(②a. 継続犯)であるとする」という文言から、⑧には状態犯と継続犯の区別を、実行行為を基準にする考え方を根拠とした場合に、継続犯となる特別な傷害罪の態様が入ることが分かる。この点、実行行為を基準にする考え方によれば、傷害行為という実行行為を継続しているような態様であれば、継続犯にあたることとなる。例えば、焼きごてを当て続けたような場合や、摂取させた薬物が効果を継続的に発揮し、新たな生理的障害を刻々に生じさせているような場合は、継続犯にあたる。そこで語句群をみると、「k. 身体を動かすたびに傷害を負うように被害者の身体をきつく縄で縛り継続的に傷害を与えた事例」が、これらに最も近く、傷害行為という実行行為を継続しているような態様といえる。したがって、⑧にはkが入ることが分かる。